



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

JUZGADO 1A INST CIV COM 22A NOM

Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 54

Año: 2025 Tomo: 3 Folio: 615-647

EXPEDIENTE SAC: 12575385 - PERNA, LUCIANA LAURA C/ MERCADOLIBRE SRL - ABREVIADO -

CUMPLIMIENTO/RESOLUCION DE CONTRATO - TRAM.ORAL

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 54 DEL 29/04/2025

SENTENCIA NUMERO: 54.

CORDOBA, 29/04/2025.

Y VISTOS: estos autos caratulados **PERNA, LUCIANA LAURA C/ MERCADOLIBRE SRL – ABREVIADO - CUMPLIMIENTO/RESOLUCION DE CONTRATO - TRAM.ORAL, Expte. 12575385**, de los que resulta que:

I. Con fecha 19/12/2023 la actora, Sra. Luciana Laura Perna, DNI 35.330.433, promueve formal demanda abreviada (trámite oral), en contra de la demandada Mercadolibre S.R.L., CUIT 30703088534, persiguiendo el pago de la suma de pesos tres millones trescientos veintiocho mil quinientos siete con noventa centavos (\$3.328.507,90) o en lo que en más o en menos surge la prueba a rendirse, e intereses hasta su efectivo pago y con costas y costos. Además, solicita la aplicación del trámite del proceso oral en los presentes, atento fundar el presente pleito en normativa consumeril.

II. Como fundamento de todo ello relata que el día 12/05/2023, fue víctima del hurto de su teléfono celular, marca APPLE, modelo IPHONE 14, n° de línea: 2325-15478939 perteneciente a la compañía “TUENTI”, en una discoteca nocturna de CABA. Dice que el suceso aconteció alrededor de las 4 de la mañana, en el “boliche” NICETO, ubicado en Niceto Vega N: 5510 y que inmediatamente de tomar conocimiento de la falta de su teléfono, quiso realizar la denuncia correspondiente, procediendo a recorrer un total de 5 comisarias, con infructuosos los intentos, hasta que pudo realizar la presentación correspondiente en la División Comisaria Vecinal (14B) de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con intervención del juzgado “MINISTERIO PUBLICO DE LA NACIÓN - FISCALÍA NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO 43.

Relata que luego de ello, procedió a llamar ese mismo día a la compañía TUENTI, a los fines de que procediesen con el bloqueo de la línea y el teléfono en su caso; suceso que no fue automático y que tuvo una demora. Expresa que a las tres horas de hacer la denuncia mencionada, dio con la ubicación del teléfono e intento en numerosas ocasiones que la policía la ayudara pero no lo logró.

Manifiesta que al día siguiente, regresó a donde fuera su domicilio al momento del hecho (en la localidad de San Andrés de Giles, aproximadamente a 100 km de CABA) y

al abrir su cuenta de Gmail tomó conocimiento de que los ladrones habían logrado desbloquear las medidas de seguridad del teléfono (Contraseña y Face Id) e ingresar a su cuenta de Mercado Pago, donde tenía su tarjeta de débito y crédito vinculadas.

Esgrime que, al revisar sus e-mail, notó el inusual ingreso de correos electrónicos provenientes Link, que el perpetrador había realizado, a través de la aplicación de MERCADOLIBRE SRL (MERCADOPAGO), numerosas compras tanto con tarjetas de crédito como de débito que se encontraban vinculadas al dispositivo en cuestión.

Describe los siguientes movimientos de cuenta: Pagos con la tarjeta de débito por un total de \$174.900. Pagos con la tarjeta de crédito por un total de \$54.404,03. Pagos con dinero disponible en MercadoPago: \$26.815-. (\$22.500 consumidos por el perpetrador y \$24.315 debitado por MercadoPago)-.

Además dice, que solicitaron tres préstamos personales a través de la APP Mercado Pago, los cuales fueron otorgados, sin ningún requisito de validación ni documentación, en un plazo de 50 minutos, cada uno de ellos por \$50.000, \$40.000 y \$50.000 a las 15.53hs, 15.57 hs. y 16.27 hs , respectivamente. Dice que, de la totalidad del dinero obtenido por préstamos, \$90.000 fueron enviados a su caja de ahorro del Banco Provincia de Buenos Aires, para consecuentemente ser gastada a través

de MercadoPago, atento tener sincronizada su tarjeta con la cuenta de MercadoPago y que los \$50.000 restantes, obtenidos por mercadocrédito, fueron extraídos, sin consentimiento ni autorización a través de Rapipago.

Señala que el único bien sustraído a su persona fue su teléfono celular, sin tener documentación de su persona en su poder para dar la autorización y/o consentimiento a dichas gestiones de tan cuantiosa envergadura.

Dice que los montos, de gran cuantía, fueron girados a su caja de ahorros del Banco Provincia de Buenos Aires, para consecuentemente ser dispuestos sin ningún otro requisito a través de su App. de MercadoPago.

Además relata que con fecha 12/05 le ingresó un pago por un servicio laboral brindado a un cliente, por la suma de \$20.000 y los perpetradores, inmediatamente procedieron a consumirlos.

Continúa relatando que, de todo lo anteriormente descripto, tomó conocimiento el día 13 de mayo, argumentando que el robo se había producido en zona céntrica de Buenos Aires (CABA) y su domicilio en ese momento era en provincia, por lo que recién allí procedió a tomar contacto con MercadoPago, reportando el robo de su teléfono y el consecuente robo de su cuenta. Además dice que, procedió a tomar contacto con Banco Provincia de Buenos Aires y Visa para desconocer los débitos y consumos realizados. Menciona que Visa procedió al desconocimiento inmediato

de los consumos realizados con la tarjeta de crédito, pero que luego de eso Mercado Pago generó un contracargo reclamándole la deuda por haber desconocido esos consumos de la tarjeta de crédito, por el importe de \$10.000 y \$18.700. En cuanto a los gastos realizados con la tarjeta de débito perteneciente al Banco Provincia de Buenos Aires, la entidad le informó que no haría lugar al desconocimiento realizado.

Expresa que también realizó los reclamos correspondientes a Mercado Pago en donde le solicitaron cierta documentación, pero que no se le dio respuesta alguna. Dice que, luego del reclamo tuvo un ingreso de aprox. \$4.400 a su cuenta de Mercadopago, dinero el cual fue absorbido automáticamente por la aplicación para cancelación del préstamo adquirido, lo que fue realizado sin previo aviso ni consentimiento de su parte.

Refiere que a la fecha de la demanda, tiene una deuda total de \$230.455, que no ha abonado. Esgrime que fue víctima de una situación de hurto y de la falta de cuidados y/o prevenciones por parte de Mercado Pago al introducir al mercado su aplicación, siendo ésta generadora de potenciales riesgos como es la posibilidad de acceder a tanto dinero de créditos sin verificación alguna.

Para resumir, dice que: Se utilizó dinero disponible en su tarjeta de débito de banco provincia de Buenos Aires por la suma de \$84.900, se solicitaron 3 préstamos personales de

Mercado Crédito por un total de \$140.000. Que de ese monto, \$90.000 fue enviado a su cuenta de ahorro del Banco Provincia de Buenos Aires y consecuentemente consumido a través de Mercadopago. Que además se realizaron consumos en su tarjeta de crédito Visa del Banco Provincia de Buenos Aires, por la suma de \$54.404, monto que fue desconocido y anulado por Visa. Que se consumió dinero disponible en Mercadopago por la suma de \$26.815, \$22.500 fueron consumidos por los perpetradores y \$24.315 fueron absorbidos por Mercadopago por la deuda que habían contraído por los préstamos personales. Por todo ello, desglosa su pretensión en los siguientes rubros y montos:

- **DAÑO EMERGENTE:** Cuantifica el rubro considerando los montos dinerarios debitados indebidamente por la accionada, el cual asciende a la suma de pesos doscientos cuarenta y un mil doscientos ochenta y cuatro con noventa centavos (\$ 241.284,9), o en lo que más o menos surja de la prueba a rendirse, con más intereses desde que son debidos.

- **DAÑO MORAL:** Dice que el daño extrapatrimonial ocasionado a su persona, es claro y ostensible, por cuanto se vio obligada por la entidad demandada al pago de sumas dinerarias las cuales no fueron requeridas, no siendo contratante de operación alguna ni deudor de ésta, además también de la persecución para el pago de montos irrisorios

no contraídos, todo lo cual le generó sentimientos de angustia, nerviosismo e impotencia, al no poder hacer cesar dichos comportamientos y hostigamientos por parte de la demandada. Dice que, durante meses y aún en la actualidad persisten momentos de angustia y sobretodo se desvela muchas noches por la angustia que le genera todo este caos en su vida que dice estar injustamente padeciendo y que la demandada es responsable. Asimismo, expresa que se vio obligada al pago de cuantiosas sumas de dinero, encontrándose potencialmente expuesta a ser informada a registros públicos de morosos, por la exclusiva responsabilidad de la conducta desconsiderada de la accionada.

Arguye que no tuvo respuesta oportuna a los reiterados reclamos formulados y tal situación aparejó ansiedad y molestias que trascienden la normal adversidad que en la vida cotidiana se verifica frente a contingencias ordinarias.

Cita jurisprudencia con referencia al tema. Por lo motivos expuestos reclama por el rubro la suma de pesos un millón seiscientos ochenta y siete mil doscientos veintitrés (\$1.687.223), con más intereses desde que son debidos, lo que equivale a un viaje todo incluido, a la ciudad de Bariloche con traslado y estadía incluidos para dos personas, por un plazo de cuatro noches, o en lo que más o menos resulte de la apreciación de S.S.

- DAÑO PUNITIVO: Dice que mediante la sanción

punitiva se persigue disuadir o desalentar a partir de una pena pecuniaria al agente dañador del consumidor, en donde no sabrá (de manera anticipada) cuál será su extensión económica. Tal cuantificación dependerá de factores individual y concretamente valorados y, muchas veces, tendrá como finalidad esencial su imprevisibilidad. Justamente, es esta inseguridad la que fundamenta la eficacia preventiva de la figura punitiva. Alega que, mediante la institución del “daño punitivo”, ya no se intenta la indemnización de un “daño sufrido”, sino la sanción al demandado violador de la ley de defensa del consumidor, como un modo de evitar que continúe con tales prácticas, y no se realicen en lo sucesivo, dando adecuada respuesta a los fines de la normativa constitucional de protección del consumidor, y su reglamentaria ley de defensa del consumidor, buscando entonces que mediante el pago de una sanción económica civil se produzca un verdadero desembolso económico, que haga recapacitar al proveedor respecto de continuar con las prácticas antijurídicas, y reacomodar y reajustar su actuación a la letra y los fines de las leyes respectivas del consumidor.

Explica que la aplicación de esta multa civil se encuentra habilitada y resulta plenamente procedente en el presente caso, en razón de haberse configurado los extremos que la doctrina y jurisprudencia ha entendido como necesarios

para la aplicación de la sanción. Dice que la demandada tuvo un trato completamente desconsiderado hacia su parte, el que se revela en los reclamos e intervenciones infructuosos que debí realizar y los meses que transcurrieron sin que al día de la fecha se le haya brindado una solución efectiva, certera y definitiva, pese a su buena fe y cooperación en todo momento.

Reitera que haber tenido que atravesar diversos acontecimientos con la demandada que le han generado un desgaste en su persona, siendo imputable a la demandada su totalmente gravoso comportamiento y la falta de interés y compromiso en el presente caso. Cita doctrina y jurisprudencia en el tema.

Solicita por el rubro la suma de pesos un millón cuatrocientos mil (\$1.400.000) o en lo que más o menos resulta de la prueba a rendirse en autos o su prudente arbitrio judicial disponga.

Funda su pretensión en derecho. Ofrece prueba. Solicita la aplicación de la normativa consumeril.

Con fecha 13/03/2024 aclara que los consumos realizados con dinero disponible en MercadoPago fueron por un total de \$22.500 por parte del perpetrador y \$24.315 debitado por Mercadopago-. Es decir, dicha suma comprende un total de \$46.815. Por ello expresa que la suma total pretendida en concepto de daño emergente asciende a un total de \$131.715, monto comprendido por \$46.815 de

transacciones realizados con dinero disponible en mercado pago y \$84.900 extraídos a través de Mercado Pago de su cuenta del Banco Provincia de Buenos Aires.

Por lo que rectifica demanda por la suma de \$3.218.938.

III. Con fecha 04/04/2024 se imprime a las actuaciones el trámite de juicio oral; Ley N° 10.555 (y modificatorias).

IV. Con fecha 02/08/2024 comparece el Dr. Sebastián Cancio y contesta el traslado corrido con motivo de la demanda. Niega de manera general y particular cada uno de los hechos alegados por la actora. Dice que la actora pretende responsabilizar a su mandante por las operaciones que un tercero habría realizado sin su consentimiento. Advierte que lo que se encuentra discutido en autos es si efectivamente un tercero ingresó a la cuenta de la actora y la operó sin su consentimiento y, llegado el caso, si corresponde o no adjudicar responsabilidad a Mercado Libre por tales hechos. Expresa que el accionar de su mandante fue en todo momento diligente, acorde a lo que le es exigido tanto desde el punto de vista legal (normativa aplicable) como convencional (cfr. Términos y Condiciones que rigen el Sitio Web).

Alega que a no existió una vulneración o una falla en los sistemas de seguridad de Mercado Libre y que Mercado Libre dio, oportunamente, una correcta respuesta al reclamo realizado por la actora en el Sitio Web, ajustándose a lo establecido por los Términos y

Condiciones. Continúa diciendo que no se encuentran reunidos los presupuestos para considerar que Mercado Libre es responsable y deba indemnizar a la actora por los hechos expuestos en autos. Que no existió una conducta antijurídica, actos u omisiones imputables a Mercado Libre, ni factores que permitan atribuirle responsabilidad civil alguna.

Manifiesta que son hechos de un tercero y la negligencia de la propia actora los que generaron y permitieron las operaciones cuestionadas. Que, Mercado Libre cumplió con todas las obligaciones a su cargo y con todas las normativas que por su actividad le resultan aplicables, no existiendo elementos que permitan atribuirle responsabilidad alguna por los hechos que la actora relata en su escrito de inicio.

Expresa que una de las herramientas que Mercado Libre pone a disposición de sus usuarios consiste en un sistema de gestión de pagos y cobros en línea que permite a los usuarios pagar y/o cobrar por los bienes o servicios que deseen adquirir o vender (“Mercado Pago”).

Dice que, para poder utilizar los servicios de Mercado Pago, es necesario que el usuario previamente se haya registrado y aceptado estos los Términos y Condiciones del Sitio Web. Que allí se le solicita que se valide su identidad. Que luego para ingresar a su cuenta el usuario utiliza las Credenciales de Acceso que registró y que deben

permanecer en su exclusivo conocimiento. Transcribe los términos de la cláusula “1.b”. Dice que la prestación del servicio de Mercado Pago se estructura a través de un contrato de mandato irrevocable otorgado por el usuario a Mercado Pago, con la finalidad de: (i) pagar o cobrar transacciones realizadas a través del Sitio Web; (ii) Pagar o cobrar transacciones realizadas por usuarios en otras plataformas de comercio electrónico distintas del Sitio Web; y/o (iii) realizar y/o recibir envíos de dinero que no tengan relación con plataformas de comercio electrónico. Argumenta que, independientemente del tipo de pago que se haga, Mercado Libre actúa como mandatario, exclusivamente por cuenta y orden del usuario respectivo, llevando adelante las instrucciones que éste le proporcione. Dice que Mercado Libre no realiza operaciones por iniciativa propia, sino respondiendo una orden emitida por un usuario. Expresa que es un servicio accesorio brindado por Mercado Libre para facilitar las transacciones entre vendedor y comprador y que la única relación y responsabilidad asumida por Mercado Libre cuando se utiliza el servicio de Mercado Pago es la de cumplir con el mandato otorgado, según los términos y condiciones expresamente estipulados en la plataforma de Mercado Pago.

Hace una explicación sobre las operaciones en Mercado Pago. Dice que los usuarios pueden recibir o enviar dinero

y utilizar el mismo para operaciones que tengan o no vinculación con publicaciones efectuadas en el Sitio Web de su mandante y que para poder realizar operaciones en las que operen como “pagadores”, previamente deben disponer de fondos en su cuenta de Mercado Pago. Expresa que los usuarios pueden ingresar fondos en su cuenta de Mercado Pago a través de: (i) medios de pago habilitados tales como tarjetas de débito y redes de cobranzas extrabancarias; (ii) cobro de operaciones realizadas a través de cualquiera de los medios de pago habilitados (dentro o fuera del Sitio Web); (iii) transferencias realizadas directamente a la cuenta de Mercado Pago. Una vez que los fondos estén acreditados y disponibles en la cuenta, el usuario puede utilizarlos, pudiendo dejar los mismos allí, utilizarlos para pagar a terceros, transferirlos a una cuenta bancaria o de pago si así lo desea, y cualquier otro uso habilitado por la plataforma.

Explica cómo se realizan las operaciones de Pago de bienes y servicios publicados en el Sitio Web, Préstamo Personal, Retiros a Cuentas Bancarias y los avisos de Mercado Libre al realizarse operaciones.

Refiere que Mercado Libre pone a disposición de sus usuarios en una extensa variedad de herramientas y mecanismos de seguridad, en lo que refiere al acceso a la cuenta, a los datos, a la información que se encuentran almacenados y a las operaciones que se realizan a través de

ella. Dice que esta obligación de seguridad en cabeza de Mercado Libre es una obligación de medios, y no de resultado. Dice que dicho deber consiste en prestar a favor de sus usuarios un sistema de seguridad idóneo, que resulte adecuado y apto para dar protección tanto su cuenta como a los datos que se encuentran almacenados en ella; ello, independientemente del resultado que en cada caso se obtenga. Acompaña Anexo VI, dice que en autos la obligación estuvo acabadamente cumplida en todo momento, por lo que, no cabe responsabilidad en relación a los hechos.

Dice que el sitio web posee numerosas herramientas que fortalecen la seguridad de sus plataformas y que también cuenta con certificaciones internacionales y procesos de auditoría que garantizan la integridad de sus sistemas y mantenimiento de los más altos estándares de seguridad.

Argumenta que Mercado Libre cuenta con un Portal de Ayuda accesible por cualquiera de sus usuarios de manera libre y gratuita. Incluso puede accederse a este portal sin tener un usuario registrado en Mercado Libre. En lo que respecta al reclamo de la Actora vinculado al supuesto robo de celular, explica que Mercado Libre cuenta con soluciones específicas para esto, accesibles desde el Portal de Ayuda. Hace una descripción de ello.

En relación al hecho debatido dice que conforme lo relatado en demanda la causa principal y necesaria de la

realización de las Operaciones Cuestionadas fue el robo de su teléfono celular por parte de un tercero, entonces, se trata del hecho de un tercero por quien Mercado Libre no debe responder. Además, dice que la negligencia, demora y falta de acción de la actora fue la co-causante de las operaciones y de las consecuencias que ahora se pretenden imputar a su mandante. Explica que la Actora no cerró su cesión en la Plataforma de Mercado Pago para que el tercero que había robado su teléfono no pudiera operar desde la misma, no activó todas las múltiples medidas de seguridad que estaban a su alcance, por lo que con su negligencia, impidió que Mercado Libre tomara otras acciones en tiempo oportuno y evitara las operaciones que ahora se cuestionan.

Explica los mecanismos de seguridad que poseía la cuenta de la actora y dice que no era la totalidad que ofrecía su mandante. Dice que la seguridad de Mercado Libre no fue vulnerada sino que funcionó correctamente. Expresa que se le envió un e-mails al momento de que se hicieran las operaciones cuestionadas, tal como ella lo afirma en su escrito de demanda. Menciona que el problema fue la negligencia de la actora y su desatención para con los consejos de seguridad brindados por su representada. Resalta que su mandante tomó conocimiento de los hechos recién el día 13/05/2023 a las 14:27 horas, fecha en que la actora realizó el reclamo en el Sitio Web, es decir, 1 día y

medio después de ocurrido el robo del dispositivo y luego de que las operaciones de autos habían sido realizadas. Dice que recién con la denuncia de robo, su mandante procedió a bloquear la cuenta y desvincular los dispositivos asociados pero las operaciones ya habían sido realizadas. Explica que, habiéndose realizado el acceso a la cuenta desde el dispositivo móvil de la actora, utilizando el patrón de seguridad configurado y pasando los factores de autenticación adicionales elegidos por ella, en modo alguno pudo implicar que la aplicación de Mercado Pago detectara algún tipo de irregularidad. Indica que, si Mercado Libre hubiese tenido la información adecuada, esto es, si la actora hubiese informado el robo de su teléfono, las operaciones no podrían haber sido realizadas, en tanto la cuenta de Mercado Pago hubiera sido suspendida antes. En resumen, dice que la aplicación de Mercado Libre funcionó correctamente, y por cada una de las operaciones vinculadas al proceso de autos, remitió a la Sra. Perna un correo electrónico dando aviso de su realización y de sus datos.

Aclara que Mercado Libre desde que tuvo conocimiento del supuesto robo del celular, actuó en consecuencia, ya que procedió a bloquear temporalmente su cuenta, desvinculándola de todos los dispositivos vigentes en ese momento, a efectos de que el usuario pueda restablecer sus Credenciales de Acceso y vincularla a los dispositivos

sobre los que efectivamente tuviese control. Reitera que no hubo una violación de la seguridad de su representada y que los mecanismos de seguridad de Mercado Libre funcionaron acordes con la información con la que ésta contaba.

Dice que el alcance del vínculo entre Mercado Libre y la actora es determinado por los Términos y Condiciones del Sitio Web. En cuanto al vínculo entre la actora y el receptor de las sumas de las Operaciones Cuestionadas, Mercado Libre no forma parte, se trata de operaciones que nada tienen que ver con el Sitio Web. Cita jurisprudencia. Explica que es improcedente el factor de atribución objetivo, además de que no existiría culpa ni dolo y que por ello no se configura en el presente caso una relación de causalidad adecuada entre el supuesto daño que alega haber sufrido la Sra. Perna y una conducta imputable a Mercado Libre. Alega culpa de la víctima. Rechaza los rubros solicitados, tanto en su entidad cuantitativa como cualitativa.

Plantea la inconstitucionalidad del art. 52 bis de la Ley 24.240. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y finalmente solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas.

V. Con fecha 12/09/2024 toma intervención la Fiscalía Civil y Comercial de 1º nominación.

VI. Con fecha 29/10/2024 se celebra la audiencia

preliminar, a la cual el Dr. Tomás de Goycoechea en carácter de apoderado de la parte actora, Luciana Laura Perna y la Dra. Maria Georgina Lingua, quien solicita la participación en el carácter de apoderada de la parte demandada Mercado Libre SRL. En ausencia de la Fiscalía interviniente.

Atento no haberse arribado a un acuerdo conciliatorio, se establece como objeto litigioso el siguiente: *“Se encuentra controvertida la sustracción del teléfono, la violación de las medidas de seguridad, la responsabilidad endilgada y la procedencia de los rubros indemnizatorios pretendidos, tanto en su entidad cuantitativa y cualitativa. Por su parte la demandada alega la improcedencia del factor objetivo de responsabilidad objetiva y subjetiva, expresando que en el caso de autos existe responsabilidad de un tercero por el cual no debe responder y culpa de la víctima.”* (sic.).

Finalmente, se pauta el plan de trabajo con relación a los elementos de convicción.

VII. Conforme constancias de la causa, se diligencia y adjunta la prueba escrita proveída en autos.

VIII. Con fecha 06/03/2025, tuvo lugar la audiencia complementaria, en la oficina de gestión de audiencias (OGA) la que se encuentra grabada en el sistema CICERO, con la presencia de la parte actora, la parte actora Luciana Laura Perna, a través del sistema Webex, y de manera personal el Dr. Tomás de Goycoechea en carácter de

apoderado de la parte actora, el Dr. Kevin Beltran quien solicita la participación en el carácter de apoderado de la parte demandada Mercado Libre SRL. Seguidamente se receptaron las testimoniales ofrecidas.

Concluida la etapa probatoria se receptaron los alegatos de las partes. La actora realiza una valoración de la prueba rendida en autos, ratificando lo solicitado en la demanda. Haciendo lo suyo la demandada.

Por su parte la representante de la Fiscalía Civil y Comercial de 1º nominación realiza su dictamen, expresando que en los presentes se encuentra subyacente una relación de consumo, que debe desestimarse el pedido de inconstitucionalidad planteado y que, conforme las pruebas de la causa se encuentra probado el hecho y los rubros reclamados por lo que debe hacerse lugar a la demanda en todas sus partes.

Por último, se dicta el decreto de autos quedando los presentes en estado de ser resuelto, conforme pase a fallo de fecha 06/03/2025.

Y CONSIDERANDO:

I. Oralidad. Previo ingresar al análisis de la causa, a mérito del tipo de trámite impreso, es interesante formular algunas aclaraciones.

Los autos del rubro han tramitado bajo la modalidad de proceso civil por audiencias, regulado por Ley 10.555, modif. por Ley 10.855 y su Protocolo de Gestión (A.R.

1815 Serie A de fecha 03/08/2023).

Por tal razón, la inmediación y la oralidad se han encontrado presentes.

A los fines de lograr los objetivos de la ley, se ha exhortado a las partes a que comparezcan de manera personal a cada una de las audiencias fijadas.

Conteste a los principios que informan el proceso oral se ha intentado, a lo largo de la tramitación y en la medida de lo posible, utilizar expresiones comprensibles para el justiciable, brindando conceptos simples a los fines de que cualquier ciudadano común que no posea conocimientos especiales sobre el derecho, pueda comprender las resoluciones adoptadas por el Tribunal.

Dicho esto, interpela en análisis de los autos traídos a despacho para resolver.

II. El litigio.

Con fecha 19/12/2023 la actora, Luciana Laura Perna, DNI 35.330.433, promueve formal demanda abreviada (trámite oral), en contra de la demandada Mercadolibre S.R.L., CUIT 30703088534, persiguiendo el pago de la suma de pesos tres millones trescientos veintiocho mil quinientos siete con noventa centavos (\$3.328.507,90) o en lo que en más o en menos surge la prueba a rendirse, e intereses hasta su efectivo pago y con costas y costos. Además, solicita la aplicación del proceso oral en los presentes, atento fundar el presente pleito en normativa consumeril.

Con fecha 13/03/2024 aclara los montos pretendidos, todo conforme argumentos que se encuentran transcritos en los *Vistos* que anteceden, a los que, en honor a la brevedad y precisión, conviene remitirse.

Citada a comparecer, contestar demanda y oponer excepciones la demandada MercadoLibre, contesta la demanda resistiendo la pretensión de la actora, conforme a los argumentos que expone en su escrito de fecha 05/12/2023. Todo conforme ha sido también materia de descripción en los apartados anteriores, por lo que a los mismos corresponde estar, a efecto de sortear innecesarias reiteraciones.

Por su parte, en la audiencia complementaria, la representante de la Fiscalía Civil y Comercial de 1º nom. dictamina que la actora encuadra dentro de los términos del artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor y que la demandada encuadra dentro de los términos del artículo 2, lo que habilita la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor.

De tal manera queda trabada la Litis.

IV. 1. Marco normativa: Corresponde tener en cuenta, a los fines de la resolución del presente, el Código Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994, vigente desde el 01/08/2015, atento que en su art. 7 dispone que se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y el objeto de la presente demanda se generó con

posterioridad a la entrada en vigencia de dicho cuerpo legal. Por otro costado corresponde tratar el planteo sobre la existencia de relación de consumo.

Como se ha reseñado, la actora invoca la aplicación del estatuto de defensa del consumidor, circunstancia que no se encuentra controvertida.

Así las cosas, el art. 1 de la Ley 24.240 actualmente vigente, expresa *“Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.”*. Por su parte el art. 2 de la ley mencionada establece *“Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley.”*

De los hechos relatados en demanda surge claramente que la parte actora, Luciana Perna, era usuaria de la aplicación

Mercado Pago, que conforme lo manifestado por la propia demandada, depende de su administración, y por lo tanto, ostenta el carácter de consumidora. Por su parte la demandada, Mercado Libre S.R.L., ostenta el carácter de proveedora o prestataria de servicio, enmarcando así en una relación de consumo. Por ende, son totalmente aplicables a la causa los principios tuitivos de los consumidores establecidos en tal ley y la interpretación de los hechos y el derecho se debe hacer a la luz de tales principios.

Así, cabe destacar de modo preliminar, lo normado por los arts. 1, 2 y 3 de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 en cuanto definen al consumidor, al proveedor y a la relación de consumo, respectivamente. No obstante ello siendo que a partir de la entrada en vigencia del régimen de unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, se han armonizado las distintas normativas que regulan el sistema de protección jurídica del consumidor, corresponde analizar la normativa vigente a la luz de lo dispuesto por el art. 7 del CCCN. Así, el art. 1092 del CCCN establece: “***Relación de consumo. Consumidor.*** *Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al*

consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social” (lo destacado me pertenece). Por su parte, el art. 1093 del CCCN, dispone: “**Contrato de consumo.** Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social.” (lo destacado me pertenece).

Asimismo, el art. 1094 del CCCN, dispone: “*Interpretación y prelación normativa. Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de éste Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor*”.

De la normativa reseñada se deriva que la relación contractual que vincula a las partes en autos, representa una “relación de consumo” circunscripta a un “contrato de consumo” -el cual no ha sido controvertido en autos- que une al “actor-consumidor” y a la “demandada-proveedora”,

en un vínculo protegido por las normas del derecho consumeril y los principios generales que rigen en la materia, a saber, principio de interpretación más favorable al consumidor, acceso al consumo sustentable, entre otros. Destáquese que en este sentido se pronuncia la Sra. Fiscal Civil de 1° Nominación interviniente (conf. dictamen realizado en el marco de la audiencia complementaria). Asimismo, se observa que el contrato celebrado entre partes también engasta en un **contrato por adhesión** a cláusulas predispuestas, por lo que resultan de aplicación, los principios y normas aplicables a esta tipología contractual. En especial, resultan relevantes los artículos 987, 988 y 989 del CCCN que establecen: “Art. 987. *Interpretación. Las cláusulas ambiguas predispuestas por una de las partes se interpretan en sentido contrario a la parte predisponente.* Art. 988. *Cláusulas abusivas. En los contratos previstos en esta sección, se deben tener por no escritas: a) las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente; b) las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente, o amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletorias; c) las que por su contenido, redacción o presentación, no son razonablemente previsibles.* Art. 989. *Control judicial de las cláusulas abusivas. La aprobación administrativa de las cláusulas generales no obsta a su control judicial. Cuando el juez declara la*

nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar, si no puede subsistir sin comprometer su finalidad”

IV. 2. Determinado el encuadre normativo del caso, corresponde analizar la procedencia sustancial del reclamo.

VI. 2. 1. Previo ingresar al tratamiento de los presentes, debemos dejar asentado que no existe controversia en torno a que la accionante poseía una cuenta en la aplicación “Mercado Pago” de la demandada, así como que se realizaron las transferencias, compras y solicitudes de crédito señaladas por la actora en su escrito inicial.

El conflicto se centra en determinar si hubo por parte de la demandada incumplimiento en su deber de seguridad que posibilitó

que un tercero ajeno a la actora pudiera vulnerar la aplicación y disponer de los fondos que se encontraban en su cuenta.

Factor de atribución

Conforme lo determinado precedentemente, se deriva que la pretensión de la accionante implica un régimen de responsabilidad basado en un factor de atribución objetivo.

En este sentido el art. 40 de la Ley 24.240, dice: *“Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o*

*servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.”*Se ha dicho que “sobre la base de la regla de 'solidaridad' establecida en el art. 40, párrafo 2º, LDC, proponía algunos caracteres tendientes a zanzar la brecha "contractual/extra-contractual" en materia consumerista, sosteniendo que "i) la responsabilidad de los proveedores respecto del consumidor se encuadra en una estructura de consumo con características propias y definidas; ii) la LDC adopta el principio de favor debilis, esto es, de protección a la parte considerada débil en la relación de consumo; iii) en particular, el régimen legal tuitivo consagra el principio in dubio pro consummatore; iv) además de las indemnizaciones de daños y perjuicios, la LDC prevé sanciones específicas en sede administrativa, y la viabilidad de aplicar una multa civil a favor del consumidor, por incumplimientos del proveedor (daño punitivo), circunstancias éstas que exorbitan el sistema general de la responsabilidad civil; v) la mayoría de los proveedores no son co-contratantes directos del consumidor o usuario, por lo que están sujetos a la responsabilidad amplia en materia extra-contractual; vi)

en todo caso, la LDC atribuye responsabilidades de tipo especial y agravada, que aseguran el resarcimiento pleno del consumidor o usuario; vii) el cúmulo de obligaciones ex lege atribuidas a los proveedores - incluso al vendedor- exceden el marco de las responsabilidades del ámbito contractual - tal como se da en caso de vicios redhibitorios, por ejemplo - pues su diseño y alcances dependen del arbitrio del legislador" (CONDOMÍ, ALFREDO MARIO; "Reflexiones generales sobre defensa del consumidor y sistema arbitral de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -primeras aproximaciones; 20/11/2011; www.infojus.gov.ar; Id SAIJ: DACF110174).

De allí surge que cuando se trata de responsabilidad por la prestación de un servicio la obligación de reparar es de naturaleza objetiva, cuestión que ha sucedido en autos. El régimen de responsabilidad objetiva establece que, acreditada la ocurrencia del hecho dañoso, no es necesario que el reclamante acredite la atribución de responsabilidad del proveedor del servicio, pues este último deberá responder por el hecho acaecido bajo su órbita y sólo se libera, total o parcialmente, si prueba que el daño sufrido por el consumidor se debe a la exclusiva culpa de la víctima, hecho de un tercero por quien no debe responder o caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto por el art. 1722 CCCN. Por su parte el art. 1757 del CCCN dispone *“Toda persona responde por el daño causado por*

el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención”.

Dado que en la actualidad, las billeteras virtuales se encuentran en auge la doctrina ha dicho que las plataformas digitales -como en el caso el servicio ofrecido por MercadoLibre/Mercado Pago- “son entornos que deben calificarse como riesgosos y peligrosos con la consecuente potencialidad de generar daños al consumidor” (Souto, Virginia; “La obligación de capacitar del proveedor en el uso de plataformas digitales”, V Jornadas Internacionales de Derecho Empresarial, 15-17 de mayo de 2024, Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires). De modo tal que su responsabilidad no se funda en la autoría material de la acción delictiva sino en el deficiente control ejercido para impedir la efectivización de la maniobra fraudulenta (*mutatis mutandi*, Torino, Lourdes María, “El consumidor financiero y la responsabilidad de la entidad bancaria ante estafas electrónicas”, EBOOK-TR 2024 (Gómez Leo-Dasso), 1097, TR LA LEY AR/DOC/757/2024). Ergo, existe por parte de los proveedores de plataformas digitales una función preventiva del daño y

tratándose de una responsabilidad de carácter objetivo pesa sobre su cabeza la demostración de circunstancias que rompan el nexo de causalidad y como consecuencia, excluyan su responsabilidad, cuestión que no ha sucedido en autos.

Es que como puede advertirse, mas allá de los fundamentos brindados al contestar demanda, no existe prueba alguna que logre demostrar la ruptura del nexo causal.

VI. 2. 2. El deber de seguridad

El contenido de la obligación de seguridad, en el marco de las relaciones de consumo, supone de manera principal incorporar al mercado productos seguros conforme a las exigencias normativas y a las expectativas legítimas del consumidor. Dicha prestación presenta un marco de complejidad que se expresa en conductas que pueden suponer, según los casos, un dar o un hacer.

El art. 42 de la Constitución Nacional, reconoce el derecho de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en la relación de consumo, no solamente a la protección de su salud, sino también a la protección de la seguridad e intereses económicos. En esta misma línea, el art. 5 de la ley de defensa del consumidor establece que los servicios prestados al usuario deben ser suministrados en forma tal, que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios. Se ha entendido que

esta norma abarca no sólo a la protección de la salud y la integridad física de los consumidores, sino también sus intereses económicos; y la obligación que ella consagra puede existir con independencia de la celebración del contrato, siempre que pueda identificarse una relación de consumo, supuesto en el cual asume el carácter de una obligación autónoma de fuente legal, derivada del principio informador emergente de la cláusula constitucional de protección de los consumidor.

Doctrina especializada en el tema, que comparto, ha dicho *“la obligación de seguridad en las relaciones de consumo está presente en toda la contratación bancaria con consumidores. Su incumplimiento supone la responsabilidad del banquero, salvo los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor o culpa de un tercero por quien no debe responder. Para una valoración adecuada de estas eximentes es preciso considerar que la cuestión no es ajena al prestador del servicio, quien debe procurar por sí o por un tercero condiciones óptimas en materia de oportunidad, seguridad y confidencialidad. Demetrio Alejandro Chamatrópulos explica cómo ese deber de seguridad del banco para con su cliente se manifiesta al haberse sustituido el sistema de atención "humana" por el "automático": la entidad debe otorgar al cliente la misma seguridad que existe si la operación se hubiera hecho a través del primero. Explica el reconocido autor tucumano*

—en un comentario a fallo — que el argumento se centra en el hecho que los actores hayan sido inducidos a error a través de un ardid, no significaba que estos debían hacerse cargo de las consecuencias dañosas, sino que ello debía ser soportado por el banco, con base en que las medidas de seguridad tomadas por este último fueron insuficientes para prevenir conductas engañosas como las que sufrieron los demandantes. No resulta en vano recordar que quienes han decidido la introducción de estas "máquinas" en el sistema bancario y, es más, quienes han promocionado intensamente su uso, son los mismos bancos. El hecho de que existan beneficios para ambas partes no nos debe hacer olvidar que el que decidió incorporar esta nueva tecnología fue el proveedor. Y se trata de una cosa claramente riesgosa y que en no pocas oportunidades experimentan fallas de diversa índole. El usuario simplemente tuvo que "acatar" el cambio en la manera de operar sin quedarle otra alternativa que aceptarla. Con base en ello, resulta indiscutible concluir que la entidad debe hacerse cargo de todos los riesgos que se derivan de la decisión tomada.” (TR LALEY AR/DOC/1657/2021 – en Arias, María Paula - Müller, Germán E. La obligación de seguridad en las operaciones financieras con consumidores en la era digital. Con especial referencia a la problemática del phishing y del vishing. Publicado en: SJA 14/07/2021, 14/07/2021, 43 -).

En el caso en particular si bien no estamos hablando de una entidad financiera, frente al consumidor las billeteras digitales o virtuales tienen igual responsabilidad. El Banco Central de la República Argentina ha definido al servicio de “billetera digital”, también conocido como “billetera electrónica” o “billetera virtual”, como el servicio ofrecido por una entidad financiera o PSP a través de una aplicación en un dispositivo móvil o en un navegador web que debe permitir, entre otras transacciones, efectuar pagos con transferencia (PCT) y/o con otros instrumentos de pago, tales como tarjetas de débito, de crédito, de compra o prepagas. Además, ha establecido no sólo que estas deben registrarse para funcionar sino que también deben arbitrar mecanismos para detectar actividades sospechosas o inusuales de las personas usuarias tendientes a mitigar el riesgo de fraude.

En efecto, entiendo que, tratándose de operaciones que implican un riesgo (el riesgo propio de la operatoria de una billetera virtual, en la que están involucrados los datos personales de los usuarios y sus bienes), las plataformas digitales deben extremar los cuidados en orden a proteger la seguridad de las transacciones de los usuarios de las tarjetas, de conformidad con lo que indica el precepto constitucional, lo que no se advierte cumplimentado en debida forma en el caso.

En este sentido se ha pronunciado recientemente la

jurisprudencia al afirmar “*De la lectura conjunta de las normas transcriptas y en base al riesgo que conlleva el servicio prestado por el banco, puede concluirse que el demandado, en función del servicio proporcionado deberá garantizar la indemnidad de los fondos depositados en las cuenta de sus cliente mediante la implementación de sistemas efectivos y la adopción de medidas adecuadas para tal cometido. En este sentido, se ha dicho que: “...el funcionamiento del sistema bancario es diseñado e impuesto por las entidades financieras, sin que el cliente pueda más que confiar en que el Banco tomará los recaudos para evitar estafas. Un sistema informático que permite operar en forma remota es naturalmente un producto riesgoso, tanto para el usuario como para el Banco, que es quien diseña, desarrolla, controla y monitorea el sistema que impone al usuario (15). Por tal motivo, es el proveedor el que tiene el deber de tomar medidas adecuadas de seguridad, para prevenir y evitar el hecho delictivo(16). ...Es por ello por lo que el riesgo generado por las herramientas digitales queda a cargo del proveedor, quien debe garantizar la misma seguridad que la brindada en los casos en los cuales la operación se efectúa de manera presencial(17)...”* (Pérez Cavanagh, Gonzalo. “Responsabilidad objetiva de los bancos por fraudes electrónicos”, Cita online: TR LALEY AR/DOC/129/2024. El subrayado me pertenece). En

definitiva, el deber de resarcir nace frente a la existencia de un accionar antijurídico por parte de la demandada que se evidencia ante el incumplimiento de las obligaciones de seguridad y debida información que las mismas deben brindar a los usuarios del sistema. ... Bajo este contexto, debemos dilucidar si la sustracción del dinero de la cuenta el actor y la suscripción del crédito preaprobado por la entidad bancaria obedeció al incumplimiento —o un cumplimiento defectuoso— del deber de seguridad a la hora de brindar el servicio de homebanking o por el contrario se demostró la ruptura del nexo causal (Conf. Camara Apel Civ. y Com 6ª -Sentencia n°22 de fecha 12/03/2024 en autos 11196484 - Posse, Javier Matias C/ Banco BBVA Argentina S.A. - Abreviado - Daños y Perjuicios - Otras Formas de Responsabilidad Extracontractual - Tram.Oral).

Por todo ello entiendo que se encuentra acreditado en autos que la demandada tenía la obligación de seguridad de mantener indemne los bienes del consumidor y adoptar todas las medidas tendientes a que su sistema de seguridad no fuera vulnerado, cuestión que entiendo no ha sucedido en autos, por lo que resulta a su cargo la reparación de los perjuicios sufridos.

A modo de colofón debo también decir que se encuentra acreditado el incumplimiento de la obligación de informar, por parte de la entidad, y la falta de toda prueba sobre las

operaciones desconocidas. Todo ello, me conduce a atribuir responsabilidad a la parte demandada, en los términos del art. 40 LDC, por el daño sufrido por el accionante como consecuencia del incumplimiento de la empresa demandada.

VI. 2. 3. Conclusiones sobre el caso.

Conforme surge de la constancia de la denuncia penal adjunta con fecha 19/12/2023, se ha logrado acreditar que el día 12/05/2023 aproximadamente a las 04:00 de la madrugada la actora sufrió la sustracción de su teléfono celular en el “boliche” NICETO, ubicado en Niceto Vega n° 5510.

Asimismo, surge de la documental adjunta que con fecha 13/05/2023 realizó el desconocimiento de las operaciones y denuncia de su teléfono celular ante Mercado Pago a lo cual se le asignó los números de reclamos 254310355 y 254304490. Cuestión que ha sido reconocido por la parte demandada.

Por otro lado, conforme respuesta de oficio adjunto con fecha 27/11/2024, se ha logrado acreditar que la actora realizó el desconocimiento de las operaciones efectuadas el día 12/05/2023 y 13/05/2023 desde la aplicación de Mercado Pago a través de la tarjeta de débito del Banco Provincia de Buenos Aires que tenía asociada a la cuanta de la aplicación, entidad que, conforme la respuesta brindada, no procedió a hacer lugar al desconocimiento

efectuado.

Por otro lado, de la pericia informática acompañada con fecha 05/03/2025 surge que la experta determinó que, al momento del hecho, la actora poseía los siguientes factores de seguridad activos en la aplicación de Mercado Pago *“Desde el 12/05/2023 están configurados Activos los parámetros de Contraseña, Teléfono, Reconocimiento Facial e E-Mail. Y se encuentran Inactivos Totp y Qr Token.”* Asimismo, confirma la perito que surge de los registros de la demandada que *“Del resultado de la última consulta surge el caso 254304490 de fecha 13/05/2023 a las 12:35:07 la actora informa el robo de su teléfono. Luego en el caso 254310355 de fecha 13/05/2023 a las 13:27:31 la actora informa nuevamente el robo de su teléfono. Donde más adelante en el mismo caso, con fecha 14/05/2023 a las 8:23:59 hay una respuesta de la demandada.”* y que existen *“Desde el 12/05/2023 hasta el 13/05/2023, hubo en total 4 transferencias y retiros en la cuenta de la actora, según surgen del resultado de la consulta”* con el detalle “cashout” por las sumas de \$9000 y \$50000 a través de la entidad Rapipago y otras con el detalle “Transferencia Bancaria” por las sumas de \$ 40000 y \$50000 a través de la entidad Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Respecto de los préstamos personales que figuran en la cuenta personal de la actora, la perito dice *“El 12/05/2023,*

hubo en total 3 préstamos en la cuenta de la actora, según surgen del resultado de la consulta.” Fecha creación 2023-05-12 14:57:24; 2023-05-12 14:51:54; 2023-05-12 15:25:19 por un monto de \$40.000, \$50.000 y \$50.000, respectivamente, todos por 12 cuotas y en estado deuda.

A su vez, la perito informa que consta en los registros de Mercado Libre que las credenciales de acceso (usuario y contraseña) del usuario PELU7038730 (ID 238639007) fueron modificadas “Actualización de Datos”, “Solicitud de modificación de Datos. Cambió Soft descriptor”, el día 12/05/2023 a las 02:25:42.021 pm.”

Como puede verificarse la pericia realizada es extensa y posee detalles técnicos que a los fines de su análisis resulta en sí dificultosa por lo que se procedió a extraer detalles necesarios a los fines de la resolución de la causa, dejando a salvo que la perito ha contestado cabalmente cada uno de los puntos solicitados.

En este contexto, luce corroborado que en forma previa a la denuncia realizada por la actora a la demandada se realizaron las transferencias y compras referidas en el escrito de inicio desde la billetera virtual que la actora tenía en la aplicación Mercado Pago de la demandada a terceros extraños sin su consentimiento.

Ahora bien, más allá de que la denuncia del hurto del teléfono celular se efectuó un día y medio después del hecho, la demandada aduce que las operaciones fueron

producto de negligencia de la actora al no poseer la totalidad de las medidas de seguridad que ponía a disposición la aplicación y que, a su entender, no hubo indicios que pudieran determinar que se estaban realizando operaciones sospechosas.

Respecto lo primero debo decir, que de la pericia informática surge que la actora poseía más de un factor de seguridad activo. Sin perjuicio de ello, la demandada enfatiza señalando que “...*había otros que Mercado Libre había puesto a disposición de la Sra. Perna y que ésta, negligentemente, había desechado, negando su activación... Dichos mecanismos, que son Google Authenticator y el QR Token, ambos explicados “ut supra”, no se encontraban activados en la cuenta de Mercado Pago de la Actora, a pesar de que se encontraban a su disposición, ofrecidos debidamente por Mercado Libre.*” Ahora bien, no puede dejar de advertirse que tales mecanismos para “fortalecer la seguridad” de la cuenta son adicionales y optativos, tal como lo expresa la demanda. Ello no exime a la demandada de su responsabilidad a los fines que los mecanismos de seguridad que sí se encontraban activos por el usuario funcionaran con un nivel de indemnidad tal, que impieran que terceros extraños violaran la seguridad y utilizaran su billetera virtual sin su consentimiento y provocando los daños que alega y prueba. No debemos olvidar que en este

tipo de aplicaciones es el proveedor quien analiza los niveles de seguridad de los mecanismos ofrecidos y los pone a disposición de los usuarios para que éste pueda operar con total tranquilidad. Ahora, si a su entender el mecanismo de seguridad por ella misma ofrecido poseía un nivel bajo de seguridad, debería no habérselo ofrecido al usuario o, en su caso, informarle de las deficiencias de seguridad que podría llegar a tener en el futuro y, a su consideración, requerir de manera obligatoria que los usuarios activaran “todos” los mecanismos brindados por ella, con el fin de cumplir con el deber de seguridad que tenía a su cargo.

En base a ello siendo la demandada la responsable de analizar los mecanismos de seguridad que ella misma pone al mercado no puede ahora venir achacarle al consumidor, que resultó lesionado, que la seguridad que poseía era insuficiente o endeble.

Es que no hay que olvidarse que estamos hablando de que la actora, resultó ser una simple consumidora que decidió utilizar una plataforma de pago y no consta que se le haya informado en forma simple y clara cuál fue el análisis realizado por la empresa proveedora para la evaluación de los mecanismos de seguridad que se le ofrecían y sus riesgos de la no activación de uno o alguno de ellos, por lo que no resulta viable excluir de responsabilidad a la entidad demandada por el simple hecho de que no tenía el

100% de los mecanismo de seguridad ofrecidos, activados, y que, por lo demás, como se dijo, no eran obligatorios. A más de ello debo resaltar que la demandada tampoco ha acreditado que, de haber tenido dichos mecanismos activos, la violación de seguridad no hubiera acaecido. Por otro lado y tal como surge de la prueba pericial rendida, resulta al menos cuestionable para una entidad con la experiencia de la demandada que no haya advertido actividades no habituales en el comportamiento de la usuaria consumidora. Adviértase que surge de la prueba rendida que se modificaron los datos de acceso a la plataforma el mismo día y a una hora aproximada del robo denunciado y que, además, los dos primeros préstamos fueron adquiridos con diferencia de minutos al poco tiempo del cambio de la contraseña. Además, luego de unas pocas horas se solicitó otro préstamo desde el mismo usuario. Ello, sumado al hecho de que en un plazo de 24 horas ya se habían efectuado cuatro operaciones más. Todas estas circunstancias debieron a todas luces ser una señal de advertencia de una posible irregularidad en el comportamiento de la usuaria, que la demandada por su entidad, experiencia y deber de seguridad, tenía la obligación de observar y actuar en consecuencia. Lo hasta aquí relatado, hace caer el argumento brindado por la accionada, puesto que debió contar con mecanismos que le advirtieran que desde la cuenta en análisis se habían

efectuado movimientos irregulares y obrar a los fines de evitar el perjuicio.

En la era en la que vivimos y, siendo de uso masivo el medio de pago utilizado mediante billeteras virtuales o digitales, lo que correlativamente, ha producido el incrementado los casos de ciberdelitos o estafas, las entidades administradoras deben necesariamente proporcionar medidas de seguridad necesarias y adecuadas para evitar que sean vulneradas por terceros atacantes. Caso contrario, resulta atinado que sean responsables por las consecuencias dañosas producidas por las fallas en su sistema de seguridad, como en el presente caso.

En virtud de ello y siendo responsable la demandada de la sustracción del dinero denunciado en la billetera virtual a nombre de la actora, corresponde hacer lugar al daño emergente requerido y en consecuencia condenar a la demandada a la restitución de las sumas de pesos ciento treinta y un mil setecientos quince (\$131.715).

A éste importe deberán adicionarse sus intereses, que, conforme los parámetros de uso judicial de este tribunal, se fijan desde la fecha del hecho, 12/05/2023, la tasa pasiva promedio que publica el BCRA con más un 3% mensual hasta su efectivo pago.

IV.1.4. Daño moral.

Expresa la actora que como consecuencia del incumplimiento al deber de seguridad y todo lo acontecido

como consecuencia de ello, le generó una situación de angustia y desvelo constante. Expresa que se vio obligada al pago de cuantiosas sumas de dinero, encontrándose potencialmente expuesta a ser informada a registros públicos de morosos, por la exclusiva responsabilidad de la conducta desconsiderada de la accionada. Menciona que jamás obtuvo una respuesta oportuna a los reiterados reclamos formulados y tal situación aparejó ansiedad y molestias que trascienden la normal adversidad que en la vida cotidiana se verifica frente a contingencias ordinarias. Por ello reclama la suma de pesos un millón seiscientos ochenta y siete mil doscientos veintitrés (\$1.687.223). En este orden, entiendo que en la defensa de los derechos del consumidor o usuario pueden ser analizados dos campos:

- a) El de los derechos patrimoniales -la seguridad de no sufrir daño, los intereses económicos, la libertad de elección, el trato equitativo y digno, la mayor protección para la parte más débil, etc. y,
- b) El de los derechos personales: la protección de la salud y la seguridad de no sufrir un menoscabo en aquella o en la vida.

Sostiene la jurisprudencia, en criterio que comparto, que las simples molestias, así como los reclamos extrajudiciales o la necesidad de accionar judicialmente para obtener el reconocimiento de un derecho, no

constituye por sí solo, daño moral, sino que es menester alegar y probar razonablemente una modificación disvaliosa en la capacidad del espíritu del querer o sentir del supuesto damnificado para así admitir tal rubro indemnización (conf. “Serafino Gustavo Adrián c/ Bco. de la Provincia de Bs. As. s/ ordinario Tribunal” Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala A, 6-feb-2004, MJ-JU-M-2651-AR | 12257 | MJJ2651).

En supuestos como el que aquí se analiza, existen circunstancias que permiten hacer excepción al principio que exige la prueba concreta del perjuicio y resulta suficiente acreditar el hecho de la acción antijurídica y la titularidad del derecho en cabeza del reclamante.

En el caso de marras, la procedencia del rubro daño moral no parece dudosa, teniendo en cuenta que las vicisitudes señaladas por el actor son de entidad suficiente. Adviértase que el accionante se ha visto obligado a litigar para exigir la restitución de lo sustraído desde la aplicación de Mercado Pago de la cual resulta administradora la demandada y que pese a todas las gestiones realizadas no pudo obtener respuestas eficaces que dieran conclusión a la problemática. Del relato de los hechos realizado por la actora y las testimoniales receptadas en la causa puede advertirse las sensaciones de angustia y padecimientos que ha tenido que soportar la accionante ante el robo de su teléfono celular y como consecuencia de ello las

sustracciones de dinero y obtención de préstamos a su nombre sin su consentimiento. Si bien la demandada refuerza su postura manifestando que la actora tardó un día y medio en realizar la denuncia a la aplicación, no creo que ello resulte relevante en la causa como para excluir su responsabilidad. Es dable advertir que el robo del teléfono celular se efectuó a la madrugada del día 12/05/2023, que la actora menciona que debió recorrer varias comisarías para realizar la denuncia y que recién la pudo efectuar a las 15:39 hs. Que además estuvo intentando recuperar el teléfono en horas de la noche y llegada la mañana con la ubicación que le informaba la plataforma de iPhone. Que luego debió trasladarse a su hogar que se encontraba en la localidad de San Andrés de Giles y que por todo ello, que no es poco, recién pudo hacer la denuncia en la plataforma de Mercado Libre.

De dicho relato puede extraerse que si bien podría haberse realizado la denuncia a la aplicación con anterioridad, en el momento del hecho, miles de cuestiones deben haber pasado por su cabeza en torno a intentar recuperar su teléfono celular y quizás no sintiendo preocupación por que pudieran ingresar a las plataforma del teléfono puesto que, bajo su conocimiento, las medidas de seguridad que brindaba la plataforma no deberían haber sido violadas. Piénsese que el reclamo efectuado en autos se trata de montos de dinero bajos, que si bien representan para

cualquier consumidor, parte de su patrimonio que se devalúa día a día, se convierte en un monto totalmente ínfimo para una empresa de las características de la demandada. Es más, podríamos decir sin temor a equivocarnos, que se trata de una de las billeteras virtuales o digitales más usadas en la Argentina por lo que la suma reclamada por la actora resultaba totalmente ínfima.

Sumado a ello, ha quedado verificado en los presentes que ha existido violación al derecho de información y al trato digno. Este último, no en cuanto a destrato hacia la persona del consumidor pero si al habersele negado información a los fines de que entienda la situación que estaba atravesando. No surge de autos que se le haya brindado una información acabada de porqué se rechazaba su reclamo. Conforme lo informe la demanda, sólo expresa que las operaciones se realizaron desde su cuenta personal y con las claves de acceso disponibles, pero no brinda más información que ello. Ahora bien, puede entenderse el menoscabo emocional que pudo atravesar el consumidor frente al hecho de tener que llegar a esta instancia sin toda la información necesaria para entender el origen del conflicto.

Además, debo sumar a ésto el modelo estandarizado de resolución de conflictos que posee la demandada. De la pericia acompañada surge que debió realizar varios reclamos y que las respuestas son genéricas y no hacen

más que solicitar datos estandarizados. No se advierte que se haya puesto a disposición un agente en particular que le haya solicitado la información necesaria en base a los datos proporcionados. Si bien no puede negarse que se le dio curso al reclamo y finalmente se le rechazó, no podemos decir que ello cumpla acabadamente con el deber de información que pesa sobre el proveedor.

Por todo lo mencionado, sumado al camino tortuoso que se ha visto obligado a transitar el accionante, me permite inferir la existencia del perjuicio que, razonablemente, debió haber experimentado en su ánimo en virtud de la situación que tuvo que padecer, lo que amerita que dicho sufrimiento espiritual sea de alguna manera compensado.

Ahora bien, en cuanto al monto reclamado debo hacer la siguiente salvedad. En autos se reclama por el rubro la suma equivalente a un viaje todo incluido, a la ciudad de Bariloche con traslado y estadía incluidos para dos personas, por un plazo de cuatro noches, lo que cuantifica al demandar en la suma de \$1.687.223.

En base a ello, debo decir que a mérito de la facultad brindada por el art. 335 del CPCC., el valor de la reparación, debe ser fijado con absoluta medida y razonabilidad, a los fines de evitar el enriquecimiento ilícito por parte del actor, por encima de su derecho a la reparación. Conforme a la naturaleza reparadora y no punitiva que tiene la indemnización por agravio

extrapatrimonial, y atendiendo en principal a la prueba desarrollada en la causa y, especialmente, el daño emergente producido, entiendo justo y equitativo, morigerar la pretensión solicitada y conceder a título de resarcimiento por daño moral, la suma de pesos quinientos mil (\$500.000) por resultar ello justo.

A este importe deberán adicionarse sus intereses, que, conforme los parámetros de uso judicial de este tribunal, se fijan desde la fecha del hecho, 12/05/2023, la tasa pasiva promedio que publica el BCRA con más un 3% mensual hasta su efectivo pago.

IV.1.4. Daño punitivo.

Por último, la actora reclama en demanda la suma de en pesos un millón cuatrocientos mil (\$ 1.400.000) concepto de daño punitivo.

En este sentido, argumenta que en autos se configuran los factores objetivos y subjetivos que justifican su aplicación. Ahora bien, previo ingresar al caso en particular debe resolverse el planteo de inconstitucionalidad del art. 52 bis de la Ley 24.240 solicitado por la demandada. En este sentido, tal como lo expresara la Fiscalía Civil al momento de dictaminar, existe vasta jurisprudencia, incluida de nuestro tribunal casatorio, que ha declarado constitucional la multa fijada en la ley consumeril.

Y bien debo decir que, el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) incorpora la figura del "daño

punitivo" en los siguientes términos: *"Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley".*

Se trata entonces, de una multa civil a favor del consumidor que puede establecer el juez en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, aclarando la norma que es independiente de otras indemnizaciones que puedan otorgarse a favor del consumidor. De hecho, la multa civil puede llegar a ser superior a la indemnización que pueda corresponder por daño moral y/o patrimonial.

Los daños punitivos han sido definidos como *"sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del*

demandado y a prevenir hechos similares en el futuro" (Pizarro, Ramón Daniel, Daño Moral, p. 453, Hammurabi, Bs.As., 1996).

La lectura armónica e integral de la ley de defensa del consumidor, en especial de lo establecido en los arts. 52 bis y 8 bis de la Ley 24.240, que han sido oportunamente citados, nos permite colegir que para la configuración del daño punitivo se requiere la conjunción de dos elementos: 1) Por un lado, un elemento objetivo, dado por el incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales por parte del proveedor (conforme lo estipula el art. 52 bis, Ley 24.240); 2) Pero además, se exige la concurrencia de un elemento subjetivo, configurado por la ejecución de cualquiera de las conductas tipificadas en el art. 8 bis (“conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”; “ejercer sobre los consumidores extranjeiros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice”; “En los reclamos extrajudiciales de deudas... utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial”).

La doctrina y la jurisprudencia se han expresado en este sentido: “Esta doctrina sostiene que no basta con el mero incumplimiento de las obligaciones (legales o contractuales) a cargo del proveedor, sino que hace falta

algo más: el elemento subjetivo que consistiría en un menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva y que se traduce en dolo o culpa (...) También es importante la opinión autoral de la Dra. Zavala de González respecto de la calificación de la conducta típica como aquella que se presente objetivamente descalificable desde el punto de vista social, disvaliosa por inercia, indiferente hacia el prójimo, con desidia, con abuso de una posición de privilegio (Zavala de González, Matilde y González Zavala, Rodolfo M. “Indemnización punitiva”, en Bueres, Alberto J. y K, Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Responsabilidad por daños en el tercer milenio” Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, pág. 188).

En la misma línea se ha sostenido que no cualquier incumplimiento debería motivar la multa civil del art. 52 bis, sino que se habla de “graves inconductas” (Cfr. PIZARRO, Ramón D. “Daños punitivos” en Derecho de Daños, Homenaje al Profesor Doctor Félix A. Trigo Represas, Segunda parte, Buenos aires, La Rocca 1993, pág. 303)”(T.S.J. in re: “Defilippo, Darío Eduardo y otro c/ Parra Automotores S.A. y otro – Abreviado - Cumplimiento/Resolución de contrato – Cuerpo de copia – Recurso de casación e inconstitucionalidad (Expte. 2748029/36)” S. 61 - 10.05.2016)

Debe tenerse presente asimismo, que la multa civil prevista en la normativa del consumidor, persigue una doble

finalidad, preventiva y sancionadora.

Así lo ha entendido la jurisprudencia del alto cuerpo provincial: *“El punto decisivo radica en la verdadera finalidad de esta institución, la que apunta a dos objetivos esenciales: prevenir el acaecimiento de hechos similares, favoreciendo la prevención de futuras lesiones y por otro, punir graves inconductas. Dichas sanciones civiles se aplican como castigo a un infractor de una norma civil, conteniendo una finalidad ejemplificadora y moralizadora, a los efectos de prevenir conductas similares que afecten los derechos de los consumidores. Así las indemnizaciones punitivas buscan el castigo de una conducta reprochable y la disuasión de comportamientos similares, tanto para el condenado como para la colectividad, cumpliendo una doble función (preventiva y punitiva)”*. (TSJ in re: “Defilippo, Darío Eduardo y otro c/ Parra Automotores S.A. y otro – Abreviado - Cumplimiento/Resolución de contrato – Cuerpo de copia – Recurso de casación e inconstitucionalidad (Expte. 2748029/36)” S. 61 - 10.05.2016).

No desconoce la suscripta, la discusión doctrinaria que gira en torno a la necesidad (o no) de la causación de un daño, como presupuesto de procedencia del reclamo de daño punitivo. Se ha dicho: *“Al respecto la doctrina no es uniforme; mientras que un sector, participa de la idea que los daños punitivos son autónomos, no requiriéndose la*

causación de ningún daño, otros, exigen la causación de un daño, aunque "mínimo" para la procedencia de los daños punitivos, puesto que entienden que su naturaleza es accesorio de los daños resarcitorios.” (Cfr. Brun, Carlos A “Sanción punitiva por grave menoscabo a los derechos del consumidor. Una nueva vuelta de tuerca a los "daños punitivos" en el Anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor” RDCO 296, 20/06/2019, 811Cita Online: AR/DOC/1434/2019).

Se ha sostenido la constitucionalidad del instituto en examen, aseverándose que "La ilicitud en el derecho en general tiene dos derivaciones posibles, la punibilidad y el resarcimiento. El ilícito penal es retributivo y está condicionado por la tipicidad, sin la cual no puede haber ilicitud. Debe configurarse el tipo penal para que pueda aplicarse la pena prevista en la norma. Por su parte el ilícito civil es en principio resarcitorio, el presupuesto de la responsabilidad civil prescinde de la tipicidad y se basa en tres pilares: el principio "Alterum non laedere" que impone la obligación de no dañar al otro, el nexo de causalidad entre el comportamiento del demandado y el daño invocado y por último en el criterio de imputación de responsabilidad (negligencia, culpa, dolo, riesgo o ex lege)."

"En el tráfico de las relaciones privadas prevalece el principio de la autonomía de la voluntad, surgido

históricamente para enervar la posibilidad del abuso del estado frente al ciudadano."

"Sin embargo en las relaciones privadas también se producen situaciones abusivas que dejan indefensa a la persona, pero no frente al estado sino frente a importantes corporaciones que generan relaciones asimétricas con quienes contratan sus servicios o prestaciones o aún frente a terceros que no han contratado con ellas pero que quedan a expensas de sus decisiones."

"Esto ha motivado al legislador a "publificar" en alguna medida el derecho privado en algunos sectores, tales como la hoy denominada "relación de consumo" y a incluir sanciones que pueden aplicarse a una de las partes de esta relación, pero desde los presupuestos civiles de responsabilidad."- "Este tipo de sanción en el Derecho del Consumidor no tiene la misma estructura que la sanción penal, vinculada a la prevención o represión de la delincuencia y en la que debe prevalecer el denominado "Principio pro Homine" porque las consecuencias de la acción penal repercuten en la persona humana de manera directa."

"La sanción punitiva en el Derecho del Consumidor se explica por la función de tutela que la Ley N° 24.240 atribuye al Estado, a los efectos de disuadir a las empresas proveedoras de incurrir en conductas reiteradas que lesionen a los bienes jurídicos protegidos por la ley de

defensa del consumidor. Por otro lado el "Principio pro Homine" no puede aplicarse a personas jurídicas, que en la gran mayoría de los casos integran como parte la relación de consumo."

"La reparación civil hace al interés privado del damnificado pero en ocasiones es insuficiente para preservar al interés público representado por la necesidad de un comportamiento lícito en las relaciones jurídicas. Ello ocurre, por ejemplo, cuando el costo de la reparación no supera el beneficio que se obtiene o podría obtenerse incurriendo en infracción. Ello provoca que muchos proveedores opten por la reparación del daño antes que evitarlo, por resultar más económico."

"La defensa del consumidor es una necesidad que surge a raíz de las relaciones asimétricas que el tráfico económico actual impone a los usuarios y consumidores e incluso a terceros ajenos a una relación contractual, como es el caso que analizamos. En este contexto la autonomía de la voluntad de los consumidores se reduce a su mínima expresión. En materia contractual a intervenir, en el mejor de los casos, en la conclusión del contrato y no en la configuración de los términos del mismo y esta autonomía puede llegar a ser inexistente cuando de manera involuntaria y a raíz de una causal no demostrada, un tercero pasa a integrar una "cartera negociable".

"Lo expuesto justifica la regulación específica del instituto

del daño punitivo, constituyendo un desarrollo acorde a lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional que establece que: 'Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno'. En consecuencia no asiste razón al recurrente en casación cuando impugna la constitucionalidad del „Daño Punitivo' ". (SCTucumán, in re "Alu, Patricio Alejandro c. Banco Columbia S.A. s/ sumarísimo (residual)" del 22.4.13, L.L.NOA 2013,777; haciendo suyos los fundamentos anteriores: CCC Jujuy, Sala II, in re "De los Ríos, Marta Susana c. Autotransporte Andesmar S.A. s/ acción emergente de la ley del consumidor" del 10.2.14, L.L.NOA 2014-333).

Por todo lo dicho, encontrándose ya resuelto jurisprudencialmente el tema planteado, tal como lo expresara la Fiscalía interviniente y en base a los argumentos brindados resuelvo rechazar el pedido inconstitucionalidad del art. 52 bis de la Ley 24.240 planteado, sin más.

Ahora sí, adentrándonos al caso que nos ocupa, se advierte que las consecuencias perjudiciales derivadas de la conducta desplegada por la proveedora, surgen evidentes de las constancias probatorias incorporadas en la causa.

Como ya hemos mencionado, en autos ha quedado corroborado que la demandada no ha cumplido con el deber de seguridad e información que pesan sobre su cabeza. También se ha podido comprobar que la accionante siguió reclamando, reiterativamente, el cumplimiento de la deuda que aquí se discute, ello incluso, luego de la interposición de la presente demanda, lo cual representa una actitud completamente alejada al respeto de los derechos del consumidor.

Por otra parte surge que los reclamos efectuados por la actora fueron receptados, se brindaron respuesta a ello, aun cuando no fueran favorables. Asimismo, accionada cumplimentó con la citación realizada en la instancia de mediación, participó activamente en el proceso que aquí nos ocupa y, por declaraciones de las partes, hasta tuvo intenciones de acordar en varias oportunidades, lo que no pudo desarrollarse por entender la accionante que no resultaba suficiente.

Todas esas actitudes, deben ser valoradas para tener en cuenta la actitud de la demandada, ya que, si bien la actora tiene fundamentos válidos para haber rechazado la oferta propuesta, vislumbra cierta predisposición para la resolución del conflicto.

Por todo ello, si bien considero justo aplicar en el caso particular la multa prevista en la normativa consumeril, a los fines de su cuantificación, debe valorarse de manera

integral la actitud de la demandada, no solo en los presentes sino a lo largo del conflicto.

Dicho esto, la graduación de la multa se establecerá en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, lo que impone una evaluación integral del contexto en que se produce la conducta sancionada; a su vez, el máximo de la multa se correlaciona con el del art. 47 inc. b) para las sanciones pecuniarias impuestas en sede administrativa.

En definitiva, esta legislación confiere al sentenciante la facultad de imponer la multa civil en favor del damnificado, que se graduará en función de la gravedad del hecho y circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Es por ello que queda librada a la apreciación judicial, puesto que no se pueden establecer reglas fijas al respecto.

Sobre el tópico, especifica la jurisprudencia que *“Lo que sanciona la ley de defensa del consumidor es la omisión o incumplimiento de los deberes u obligaciones a cargo de prestadores de bienes y servicios que fueron impuestos como forma de equilibrar la relación prestatario-consumidor...Se trata por tanto de infracciones formales donde la verificación de tales hechos hace nacer por sí la responsabilidad del infractor. No se requiere daño concreto sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley, sin que pueda ser causa exculpatoria*

el hecho de que haya mediado "omisión", como alega en el sub lite el sancionado por carta del 22.09.05 remitida a la Dirección Jurídica de Protección al Consumidor (fs. 156, s.d.r.)” (Conf. “Díaz, Cisneros Adriano Patricio c/ Cti PCS S.A. s/ ordinario –Tribunal- Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial- Sala B 9-dic-2009- MJ-JU-M-53700-AR | MJJ53700 | MJJ53700).

Sentado lo anterior, corresponde considerar que el art. 49, LDC establece que para la aplicación y graduación de las sanciones, se tendrá en cuenta: 1) el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor; 2) la posición en el mercado del infractor; 3) la cuantía del beneficio obtenido y el grado de intencionalidad; 4) la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización; y, 5) la reincidencia y demás circunstancias relevantes del hecho (CN Cont. Adm. Fed., Sala III, 02.12.97, "Berta, Pomp c/ Sec. de Comercio e Inversiones - Disp. DNCI N° 3427/95").

Y bien, analizadas las constancias de la causa, se advierte que en el caso luce procedente la aplicación de la sanción civil nominada “daño punitivo”. Doy razones.

La empresa demandada es una reconocida empresa en el mercado y, como ya lo dijimos, tiene a su cargo una de las billeteras virtuales más utilizadas en la Argentina. En el caso de autos, resulta claro que la firma demandada, ante los sucesivos reclamos e intimaciones de la accionante,

adoptó una conducta configurada por su accionar omisivo, dilatorio y negligente, que debe ser calificada como grave y merecedora de la sanción punitiva reclamada. Recuérdese que la parte actora realizó varios reclamos y jamás obtuvo respuesta certera sobre porque se rechazaba el desconocimiento de las operaciones denunciadas.

A más de ellos, puede advertirse, que el hecho de continuar requiriendo el pago de la deuda mediante notificaciones e intimaciones representa una conducta grave configurada por su accionar desaprensivo y en total desinterés, en claro menoscabo del trato digno que debe otorgársele al consumidor y contrario con la obligación de información que pesa sobre su cabeza.

Así las cosas, merituadas la totalidad de las pruebas de la causa y haciendo una valoración íntegra de la conducta del demandado considero justo condenar al pago de la multa prevista en el art. 52 bis de la Ley 24.240 al encontrarse reunidos los recaudos exigidos por dicha normativa. En coincidencia con lo dictaminado por la Fiscal Civil interviniente.

Por todo ello, valorando: la actitud de la demandada en el caso en particular; el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor; la posición en el mercado del infractor; la cuantía del reclamo principal y el beneficio obtenido; el grado de intencionalidad y la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su

generalización; entre otras cuestiones, entiendo que en el caso bajo examen, es equitativo y justo justipreciar la multa, en la suma de pesos un millón (\$1.000.00) cuestión que así decido.

Dicha suma llevara intereses que, conforme los parámetros utilizados por el tribunal, se fijan en la tasa pasiva del BCRA con más el 3% nominal mensual desde la fecha de la presente resolución hasta su efectivo pago.

V) Costas. Conforme el principio objetivo de la derrota, las costas se imponen a la demandada, por resultar vencida (art. 130 CPCC). Situación que no se ve obscurecida por el acogimiento en una cantidad menor a la solicitada de los rubros daño moral y punitivo, por cuanto lo que importa es, en verdad, el acogimiento en sí de la pretensión y no tanto su estimación o valor definitivo, máxime cuando su cuantificación, depende del prudente arbitrio judicial. En la especie, el responsable de la generación del hecho ilícito, es el demandado, según se explicó en el considerando precedente, por lo que estimo justo que las costas sean aplicadas a ellos en la medida de la procedencia de la acción.

Deberá observarse al momento de la regulación de los honorarios profesionales del letrado de la actora, Dr. Tomas De Goycoechea, lo normado por los art. 26, 27, 29, 30, 31 inc. 1, 36 –punto medio de la escala-, 39 y concordantes de la ley 9459-, sin perjuicio del mínimo

legal y de lo dispuesto en el artículo 36 in fine de la mencionada ley. Se debe tomar como base para la regulación de honorarios del letrado, el monto de la condena con más los intereses establecidos en el considerando precedente (arg. art. 31 inc 1º, ley 9459), base que a la fecha de la presente regulación asciende a la suma de pesos tres millones doscientos trece mil ochocientos treinta y tres con cuatro centavos (\$3.213.833,04).

Para fijar el punto medio citado del artículo 36 (22,5%), he tenido en cuenta el éxito obtenido en la labor encomendada; los valores económicos en juego; las etapas procesales cumplidas; y la complejidad de las cuestiones en debate (art. 39, ley 9459), sin perjuicio del mínimo legal previsto para este tipo de juicios.

Los honorarios de la perito Oficial Informática Ariadna Marina Dacci Piccoli, se estipulan la suma equivalente a diez (15) *jus* al día de la presente regulación, es decir la suma de pesos doscientos cincuenta y un mil ciento cincuenta y seis centavos (\$485.226), al tiempo de esta resolución (arg. art. 49, ley 9459). Para ello, he tenido en cuenta la naturaleza, complejidad, extensión, desarrollo argumentativo, tiempo empleado y la dedicación asumida en la labor encomendada, y según las pautas establecidas en el artículo 39 de la ley 9459.

Sobre los emolumentos regulados a favor de la perito,

deberá adicionarse -si correspondiera- el porcentaje correspondiente a la contribución al Régimen de Previsión Social establecido por la Ley aplicable a la actividad profesional de que se trate. Dicha contribución estará a cargo de quien deba satisfacer los honorarios del profesional actuante.

Los honorarios regulados devengarán un interés (art. 35, ley 9459) desde la fecha de la presente resolución y hasta su efectivo pago igual al de la tasa pasiva promedio mensual del BCRA, más el 3% nominal mensual.

Se debe adicionar el porcentaje en concepto de IVA en caso de corresponder de conformidad a la situación tributaria que revistan los profesionales al momento del pago.

No se regulan honorarios a los letrados de la parte demandada a tenor de lo establecido en el art. 26 de la Ley 9.459 (a contrario sensu).

Por todo ello y normas citadas,

RESUELVO:

I) Hacer lugar a la demanda incoada por Luciana Laura Perna, DNI 35330433, en contra de Mercadolibre S.R.L., CUIT 30-70308853-4 y en consecuencia, condenar a este último a abonar a la parte actora, en el término de diez días los siguientes rubros y montos:

1. Daño emergente: \$131.715
2. Daño moral: \$500.000

3. Daño punitivo: \$1.000.000

Todo ello con más los intereses establecidos en el considerando pertinente.

II) Imponer las costas a la demandada Mercadolibre S.R.L., CUIT 30-70308853-4.

III) Regular de manera definitiva los honorarios profesionales del Dr. Tomas De Goycoechea en la suma de pesos un setecientos veintitrés mil ciento doce con cuarenta y tres centavos (\$723.112,43), con más la suma de pesos noventa y siete mil cuarenta y cinco con veinte centavos (\$97.045,20) en concepto de lo dispuesto por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459.

IV) Regular de manera definitiva los honorarios de la perito oficial Informática, Ariadna Marina Dacci Piccoli, en la suma de pesos cuatrocientos ochenta y cinco mil doscientos veintiséis (\$485.226) (arg. art. 49, ley 9459), a lo que deberá adicionarse -si correspondiera- el porcentaje correspondiente a la contribución al Régimen de Previsión Social establecido por la Ley aplicable a la actividad profesional de que se trate. Dicha contribución estará a cargo de quien deba satisfacer los honorarios del profesional actuante.

V) Los honorarios regulados devengarán un interés (art. 35, ley 9459) desde la fecha de la presente resolución y hasta su efectivo pago igual al de la tasa pasiva promedio mensual del BCRA, más el 3% nominal mensual.

VI) Se debe adicionar el porcentaje en concepto de IVA en caso de corresponder de conformidad a la situación tributaria que revistan los profesionales al momento del pago.

VII) No regular los honorarios a los letrados de la parte demandada, Dres. Sebastian Jose Cancio y Maria Georgina Lingua, a tenor de lo establecido en el art. 26 de la Ley 9.459 (a contrario sensu).

Protocolícese, hágase saber y dese copia.

Texto Firmado digitalmente por:

ASRIN Patricia Veronica

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2025.04.29